

1500751-20.2021.8.26.0472
Classe: Termo Circunstanciado
Assunto: Resistência
Magistrado: VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA
Comarca: Porto Ferreira
Foro: Foro de Porto Ferreira
Vara: Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 22/06/2022

... já teve passagem pela Polícia por Tráfico e está respondendo o processo em liberdade; que, o declarante tem muita amizade com Gabriel e tinha vindo na semana passada por esta cidade de Porto Ferreira; que, naquela ocasião o declarante não comprou entorpecentes em Porto Ferreira, pois já tinha trazido seu baseado da cidade em que reside; que, o interrogando se compromete a comparecer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Porto Ferreira
Foro de Porto Ferreira
Juizado Especial Cível e Criminal
Rua Dr. Carlindo Valeriani, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às17h00min

1500751-20.2021.8.26.0472 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500751-20.2021.8.26.0472
Classe - Assunto
Termo Circunstanciado - Resistência
Autor:
Justiça Pública
Réu:
GABRIEL FELIPE DE OLIVEIRA e outro

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de SIDNEY RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR e GABRIEL FELIPE DE OLIVEIRA, já qualificados nos autos, como incurso no topo do artigo 150, § 1º, do Código Penal afirmando que em 17 de maio de 2021, por volta de 00h50min, na rua João Boneli, n.º 206, Bairro Porto Bello, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, a fim de evitarem eventual abordagem policial, entraram clandestinamente e astuciosamente, estando na posse de uma faca, na residência de Alexsandro Paes da Silva.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, "os denunciados, que são moradores da cidade de Santa Rosa do Viterbo/SP e possuem antecedentes criminais, encontravam-se na data dos fatos nesta comarca por motivos não devidamente esclarecidos e, quando passavam pelo endereço acima mencionado, já no período noturno/madrugada, avistaram uma viatura policial. Ato contínuo, para evitarem eventual abordagem policial, os denunciados entraram, clandestina e astuciosamente, na residência de Alexsandro Paes da Silva, pulando os telhados e muros das residências vizinhas, estando GABRIEL na posse de uma faca. Contudo, Alexsandro, que é policial militar e reside no local com sua esposa Lucineide Maria da Silva e seus dois filhos menores de idade, ouviu o barulho dos denunciados andando sobre o telhado de sua casa, razão pela qual armou-se de seu revólver calibre 38, devidamente registrado (fls. 26/37) e se dirigiu ao quintal do imóvel, onde acabou por surpreender aqueles forçando a entrada na residência, tendo, então, de pronto ordenado que cessassem a ação, dizendo-lhes: "Parados, Polícia". Neste

momento, GABRIEL, que estava com a faca nas mãos, fez um gesto brusco e Alexsandro, agindo em legítima defesa, efetuou um disparo em nível mais baixo para cessar a ameaça, atingindo-o na perna. Na sequência, Alexsandro rendeu os denunciados e pediu a sua esposa que acionasse o resgate e a Polícia Militar, o que foi feito." A denúncia foi recebida e o processo seguiu seu trâmite natural, com apresentação de defesa prévia, audiência de instrução e julgamento e alegações finais.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Prescreve o Código Penal:

Violação de domicílio

Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

§ 1º - Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

§ 2º - (Revogado pela Lei nº 13.869, de 2019)

§ 3º - Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências:

I - durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência;

II - a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser.

§ 4º - A expressão "casa" compreende:

I - qualquer compartimento habitado;

II - aposento ocupado de habitação coletiva;

III - compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade.

§ 5º - Não se compreendem na expressão "casa":

I - hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta, salvo a restrição do n.º II do parágrafo anterior;

II - taverna, casa de jogo e outras do mesmo gênero.

Como se pode depreender por interpretação a contrario sensu do inciso I do §4º, o objeto jurídico da proteção penal é a casa (domicílio, residência, moradia), não o imóvel (o titular do direito é o morador, não o proprietário). Trata-se de proteção ao bem eleito pelo constituinte originário no inciso XI do art. 5º.

Trata-se de tipo misto alternativo para as condutas de entrar e permanecer.

A clandestinidade está relacionada com a ausência de percepção do morador, ao passo que a astúcia está ligada a algum tipo de fraude (como o disfarce).

A contrariedade da vontade pode ser tácita, como prevê o tipo, o que se dá quando se pode inferir das circunstâncias do caso a oposição do morador.

A oposição deve ser do morador ("quem de direito") e pode inclusive ser contrária ao proprietário sob determinadas circunstâncias.

Dúvidas surgem quando há vontades contrárias (áreas comuns de condomínio, áreas de habitação coletiva, divergências entre pais e filhos, esposo e esposa). Muitos doutrinadores buscam no direito privado quem teria a faculdade de permitir ou proibir o acesso de terceiros. Todavia, a questão perde força se o cenário de divergência torna incerta a consciência da ilicitude, parte essencial do dolo, que é o único elemento subjetivo compatível com o tipo.

Na modalidade entrar a consumação é instantânea, ao passo que na modalidade permanecer exige-se um tempo juridicamente relevante.

Quando a violação de domicílio é mera etapa para a realização de outro delito fica absorvida por este, ainda que seja menos grave.

No caso em exame, há prova da existência do crime e de sua autoria.

A existência do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 18/21, pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 22/23, laudo pericial de fls. 125/130, e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

A testemunha de acusação, Lucineide Maria da Silva, na fase policial disse que "na data dos fatos estava em sua residência juntamente de sua família, quando por volta das 00:50 ouviram barulhos de pessoas andado por cima do telhado, bem como a seguir, nos fundos da casa; que reside com seu marido e dois filhos de 17 e 13 anos de idade; que seu marido é bombeiro e que de imediato ele pegou sua arma de fogo do tipo revólver 38; que seu marido foi até o quintal, armado e ao verificar no portão, constatou que dois indivíduos desconhecidos estavam forçando o ingresso na casa; que seu marido gritou aos indivíduos " Parados, Policia", sendo que um dos dois indivíduos estava com algo na mão e fez um gesto brusco, momento em que seu marido efetuou um disparo de arma de fogo; que seu marido mandou que os indivíduos deitassem, sendo que estes deram alguns passos e cumpriram o determinado; que logo após o marido da ora declarante lhe pediu que trouxesse uma lanterna e que também chamasse o Resgate e a Policia; que, seu marido Alexsandro manteve os indivíduos deitados ate a chegada da viatura policial, que foi possível verificar que o indivíduo que foi atingido pelo disparo de arma de fogo tinha próximo a si uma faca." Em juízo, manteve sua versão.

A testemunha de acusação, o policial militar/bombeiro Alexsandro Paes da Silva, na fase policial disse que "é bombeiro da Polícia Militar, lotado no pelotão de Porto Ferreira e, nesta data estava em sua residência, quando por volta das 00:50 ouviu barulhos de pessoas andado por cima do telhado, bem como a seguir, nos fundos da casa em que reside; que, o declarante mora com sua esposa Lucineide e dois filhos de 17 e 13 anos de idade; que, o declarante de imediato pegou sua arma de fogo do tipo revólver, calibre 38, da marca Rossi, niquelado, numero J113186, capacidade de seis tiros, o qual estava municiado com cartuchos do mesmo calibre; que, o declarante foi até o quintal, armado e ao verificar no portão, constatou que dois indivíduos desconhecidos estavam como que forçando o ingresso na casa;que, de imediato o declarante declinou a atividade que exerce, dizendo " Parados, Policia", sendo que um dois indivíduos que estava com algo na mão fez um gesto brusco, momento em que o declarante efetuou um disparo de arma de fogo;que, como o declarante não divisou detidamente a ameaça que representava o objeto portado, efetuou um disparo de arma de fogo em um nível mais baixo, tentando apenas cessar a ameaça eminente; que, o declarante incontinenti mandou que os indivíduos deitassem, sendo que estes deram alguns passos e cumpriram o determinado; que, o declarante pediu sua esposa que trouxesse a lanterna, pois não a havia encontrado inicialmente, e pediu que sua esposa chamasse o Resgate, bem como, para a Policia; que, o declarante manteve os indivíduos sob custódia ate a chegada da viatura, tendo verificado que o indivíduo que foi atingido pelo disparo de arma de fogo tinha próximo a si uma arma branca, do tipo faca; que, o declarante acredita que foi o objeto que este trazia consigo quando se viu ameaçado e efetuou o disparo; que, o declarante esperou a chegada da viatura policial e entregou sua arma de fogo aos Pms que apresentaram a ocorrência, cabendo ressaltar que a arma está devidamente regularizada junto a PMESP; que, o declarante trabalhou por dez anos no Policiamento de área e já participou de várias ocorrências policiais, sendo a primeira que teve que utilizar de disparo de arma de fogo para cessar uma ameaça a sua incolumidade física e de familiares." Em juízo, manteve sua versão.

A testemunha de acusação, o policial militar Pedro Henrique Maciel D'andréa, na fase policial disse que "nesta data estava de serviço juntamente com o Pm Custodio na Vtr I-38413, quando foram acionados via Copom para atendimento de ocorrência de Disparo de arma de fogo, em que o solicitante Alexsandro Paes da Silva, Bombeiro Militar estava solicitando apoio; que, ao chegarem no local constataram que dois indivíduos estavam sob custodia de Alexsandro, no corredor que dá acesso a casa daquele, estando um destes, identificado como GABRIEL FELIPE DE OLIVEIRA com um disparo de arma de fogo na perna esquerda, sendo encontrada próximo ao mesmo uma

faca, com resquícios de substância hematoíde; que, quanto ao outro indivíduo, identificado como SIDNEI RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, este não tinha qualquer dano a sua integridade física; que indagados sobre os fatos os indivíduos disseram que haviam se assustando com umas luzes, que acreditaram serem da Polícia e haviam pulado por sobre os telhados da casa, vindo a entraram na casa do Policial Bombeiro Alexsandro; que, os indivíduos não esclareceram o motivo pelo qual estavam com tanto receio de viatura policial; que, a arma de fogo utilizada por Alexsandro tratava de um revólver da marca Rossi, calibre 38, niquelado, capacidade de seis tiros, municiado com seis cartuchos integros e um deflagrado, numero J113186, devidamente regularizado na Policia Militar; que, o Resgate chegou ao local e levou Gabriel ao PSM onde este teve que ficar internado, e será submetido a uma operação, sem risco de morte; que, Sidnei foi levado ao PSM local, onde passou por exame de corpo de delito, sendo necessário uso de algemas para segurança deste e da guarnição policial; que, o depoente não conhecia os indiciados, apenas o Bombeiro Militar Alexsandro." Não foi ouvido em juízo.

SIDNEY RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, em declarações perante a autoridade policial disse que "nesta data veio com seu amigo Gabriel Felipe na casa do tio daquele no Bairro Cristo Redentor, sendo que não chegaram a ir na casa do mesmo; que, o declarante e Gabriel são usuários de Maconha e Cocaina e estavam no bairro procurando um local para comprarem entorpecentes; que, em dado momento o declarante viu uma viatura da Policia e resolveu correr junto com seu amigo Gabriel; que, o declarante não tem certeza, mas acredita que Gabriel tem passagem pela Polícia, pois disse que tinha que pagar multa no Fórum; que, o declarante e Felipe correram porque ficou com medo de apanhar da Polícia, pois não reside nesta cidade e já tem passagem pela Polícia; que, passaram a entrar nas casas que estavam pela frente e correr por sobre os telhados, e quando desceram em um casa, ouviu um "barulho de bomba"; que, o individuo disse que era Policia e mandou que os dois deitassem no chão; que, o declarante não foi alvejado e aguardaram a chegada da Policia Militar no local; que, o declarante notou que Gabriel havia sido atingido por um disparo de arma de fogo na perna; que, o declarante ou Gabriel não foram agredidos no local, e apos ambos foram levados ao PSM local, onde passaram por exame de corpo de delito; que, o declarante estavam com a quantia de RS50,00 para comprar entorpecentes, mas acredita que em sua correira por sobre os telhados acabou por perder; que, o declarante já teve passagem pela Polícia por Tráfico e está respondendo o processo em liberdade; que, o declarante tem muita amizade com Gabriel e tinha vindo na semana passada por esta cidade de Porto Ferreira; que, naquela ocasião o declarante não comprou entorpecentes em Porto Ferreira, pois já tinha trazido seu baseado da cidade em que reside; que, o interrogando se compromete a comparecer a Jecrim quando for intimado." Revelia decretada às fls. 267.

GABRIEL FELIPE DE OLIVEIRA, em declarações perante a autoridade policial disse que "nesta data estava com seu amigo Sidnei e foram no Bairro Porto Belo a fim de comprarem entorpecentes; que, em dado momento, Sidnei disse que tinha avistado uma viatura e começaram a correr; que, como não são residentes nesta cidade, ficaram com medo de serem abordados e "zuados"; que, começaram a entrar nos terrenos de algumas casas e subiram nos telhados, vindo a descer no corredor de uma casa; que, neste momento ouviram um barulho e o interrogando sentiu que algo o havia atingido, tendo um homem dito que era Policia; que, logo após Policiais chegaram no local e vieram a levar o interrogando ao PSM, bem como seu amigo Sidnei; que, o interrogando não sofreu qualquer agressão por Parte do Policial Militar que o deteve, ou dos Pms que estão apresentando a ocorrência nesta Unidade; que, o interrogando não portava qualquer arma branca, e não sabe de quem seja a encontrada." Não foi ouvido em juízo, pois, apesar de regulamente intimado, não compareceu, sendo decretada a sua revelia.

Com a devida vênia à defesa técnica, o dolo pode ser auferido das circunstâncias amealhadas pela prova testemunhal dando conta de que as pessoas imputadas se esconderam para fugir de uma possível abordagem policial. E nesse intuito não respeitaram o direito da família que ali morava. O imóvel não

constituiu rota de passagem para fuga, mas verdadeiro esconderijo frente às forças de segurança do estado.

Além disso, as condutas imputadas não consistiram em meios para outras condutas ilícitas, o que poderia afastar a imputação (consunção) ou eventualmente até o dolo.

Entender como lícita as condutas imputadas implicaria reconhecer que a cláusula constitucional de inviolabilidade de domicílio valeria somente contra a polícia. Além disso, teria por efeito diminuir a eficácia da proteção constitucional, vez que, permitida essa conduta aos suspeitos, caso a infração penal sob suspeita fosse permanente, logo estaria autorizada a polícia a também entrar no imóvel. É inegável o efeito deletério dessa exegese (art. 5º do Decreto-Lei 4.657/42).

Configurado, assim, o delito de violação de domicílio, qualificado pela circunstância da noite e do concurso de pessoas, cujo preceito secundário prevê pena de "detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência".

Passo a dosar a pena.

Ressalto que a fixação dos aumentos da primeira fase sobre a pena mínima constitui procedimento contrário à lei. Apesar disso se aplicar a qualquer tipo penal, a contrariedade é notada mais facilmente nos casos em que há grande intervalo entre a mínima e a máxima, quando esta se torna impossível, frustrando a determinação do legislador.

Na hipótese do tráfico o aumento teria de ser de dois inteiros para se chegar aos quinze anos! Desnecessário maior esforço para ver o efeito catastrófico desse procedimento em crimes como o peculato ou o homicídio qualificado. Nunca se chegará ao máximo, o que, na prática, contraria frontalmente a lei.

Mais, o procedimento que toma como base de cálculo a pena mínima gera outra injustiça. Percebe-se que em alguns casos a qualificadora somente aumenta a pena máxima; é o que ocorre, a título de exemplo, com a lesão simples no âmbito da violência doméstica. Ora, calcular os aumentos tendo por parâmetro a pena mínima é ignorar o comando legal que deu especial gravidade ao delito cometido naquela situação específica.

Sem contar os casos em que o intervalo de pena é menor que a pena mínima (§3º do art. 302 da Lei 9.503/97, artigos 267, 270 e 273 do Código Penal, entre outros), quando a utilização somente desta causa considerável prejuízo ao réu.

As situações e razões aqui trazidas são suficientes para demonstrar que a fixação da pena na primeira fase levando em conta somente a pena mínima contraria a lei e o sistema de imposição de sanções por ela previsto.

Ora, como o legislador estabelece sempre um mínimo e um máximo, ambos são a medida legal da gravidade do delito, de modo que o procedimento mais adequado para perceber essa grandeza em sua inteireza é levar em consideração justamente o intervalo de pena, ou seja, a diferença entre o máximo e o mínimo legal; aplica-se o aumento sobre o intervalo, adicionando a pena mínima.

É o que recentemente vem fazendo o STJ:

Considerando o intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena abstratamente prevista para o delito de sonegação fiscal e a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se afigura desarrazoada ou desproporcional a exasperação da basilar em apenas 1 (um) ano acima do mínimo legal, porquanto, na compreensão das instâncias ordinárias, suficiente à prevenção e reprovação do crime.

STJ, AgRg no AREsp 1194509/MG, Quinta Turma, rel. Min. José Ilan Paciornik, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018.

A gravidade concreta do delito, praticado por pessoa que é integrante da polícia militar e que mais do que qualquer outro servidor público deve primar pela respeitabilidade de sua instituição e preservar o pundonor que rege a caserna; bem

como o modo de execução, tratando-se de delito praticado por meio de grave ameaça e violência moral, justificam a fixação da pena-base 2 anos acima do mínimo legal, tendo em vista o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, que vai de 2 anos a 8 anos de reclusão.

STJ, AgRg no REsp 1678420/PA, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018.

Descabe falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base pela culpabilidade, pois, considerando a fração de aumento ideal de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 18 anos, chega-se ao incremento da reprimenda em 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora, ou seja, em patamar inferior ao estabelecido no decreto condenatório.

STJ, HC 448811/PR, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018.

Quanto aos maus antecedentes, descabe falar em desproporcionalidade no aumento da pena em 6 meses, considerando a presença de dois títulos condenatórios a serem valorados na primeira fase da dosimetria, assim como o intervalo do apenamento estabelecido no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. STJ, HC 451487/MS, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018.

Mantém-se a valoração negativa das vetoriais analisadas pelo v. acórdão impugnado, tendo em vista a fundamentação concreta apresentada, descabendo falar em desproporcionalidade na fixação da pena-base em 5 (cinco) anos e 12 (doze) dias de reclusão, considerando o critério ideal de aumento por circunstância judicial desabonadora, a incidir sobre o intervalo de apenamento estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, o qual corresponde a 6 anos.

STJ, HC 446462/SP, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018.

É também a posição do Plenário do STF:

Ausente a alegada desproporcionalidade entre os parâmetros utilizados na dosimetria das penas dos crimes de corrupção ativa e formação de quadrilha, sobretudo porque se tratam de delitos cujas objetividades jurídicas são distintas e que apresentam diferentes intervalos penais nos respectivos preceitos secundários.

AP 470 EDj-sétimos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 05/09/2013, DJe 10/10/2013.

Não se aplica um critério meramente matemático de comparação entre penas cominadas a delitos distintos, com intervalos diversos entre a pena máxima e a pena mínima, sob pena de violação do princípio da individualização.

AP 470 EDj-vigésimos quartos/MG, Plenário, rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 28/08/2013, DJe 10/10/2013.

Aliás, em ações de competência originária das cortes superiores a dosimetria no intervalo da pena é uma constante.

Por exemplo, nos dois títulos penais condenatórios emitido pela Suprema Corte em 2019 (AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019, e AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020) nota-se claramente este procedimento (grifos nossos – diversos do original):

13.a.1) Quanto ao crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de três anos de reclusão e máxima de doze anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

13.b.1) Relativamente ao crime de empréstimo vedado (art. 17 da Lei 7.492/1986) (...) cumpre que a pena-base, considerada a pena mínima de dois anos de reclusão e máxima de seis anos, seja fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão;

AP 892/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 20/05/2019.

No juízo de individualização da pena à luz do caso concreto, anoto que a sanção cominada de forma abstrata ao crime de lavagem de dinheiro é de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, nos termos do art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998. (...) fixo-lhe a pena-base, para cada delito de lavagem de dinheiro, em 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.
AP 1030/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgada em 22/10/2019, DJe 13/02/2020.

A dosimetria foi adotada por unanimidade pelos dois colegiados, conforme extratos de ata.

Não diverge a Segunda Turma do Pretório Excelso. Na condenação em ação penal originária (AP 644/MT, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 16/03/2018) assim se pronunciou:

(...) deve-se observar as penas originalmente cominadas, "reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa" (...) Considerando a particular gravidade das circunstâncias mencionadas, estabeleço a pena-base em 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Em sentido idêntico a Corte Especial do STJ (APn 327/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 18/12/2018, DJe 19/12/2018):

Os fatos narrados ajustam-se aos elementos configuradores do delito de peculato-desvio (art. 312, 2ª parte do Código Penal). (...) Portanto, diante destas três circunstâncias judiciais altamente desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal. Assim, sopesadas tais circunstâncias e observadas a razoabilidade e a proporcionalidade da reprimenda para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do crime, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Observar no voto acima que o aumento na pena corporal é idêntico ao da pena de multa, caso se considere o intervalo das penas (30% dos intervalos).

Tampouco se faz aqui tarifação de aumentos em tabelas predeterminadas. Além de não haver respaldo legal, isso fere de morte o espírito do Código Penal que estimula a valoração concreta dos elementos do caso.

Não se há falar em tabelamento das reprimendas, nem mesmo em institucionalização da pena mínima.

TJSP, Apelação n. 0000142-53.2017.8.26.0472 , 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Costabile e Solimene, j. 23.08.2018.

Preambularmente, lembro que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vitoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base.

AP 996/DF, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 29/05/2018, DJe 08/02/2019.

Segundo o procedimento que valora cada circunstância judicial com um aumento de 1/6

ou 1/8, merecerá a reprimenda máxima o fato criminoso em que estiverem presentes todas as circunstâncias, pouco importando as suas gravidades, ao passo que um fato criminoso envolto em somente uma circunstância negativa, mas presente em um grau absurdo, sofrerá um aumento mínimo.

Ora, isso é uma má interpretação sobre o sistema de imposição de penas estabelecido pela Reforma de 1984 e um descumprimento da Constituição na medida em que esta impõe a individualização da pena, a qual necessita uma valoração da gravidade concreta das circunstâncias, e o art. 59 do Código Penal exige que a fixação da pena atenda à finalidade de reprovação e prevenção do crime, o que também não se alcança com tabelamentos.

Como diz Roberto Lyra nos seus comentários ao Código Penal, a adoção de um sistema de penas inflexíveis estabelece uma igualdade que é a pior das iniquidades. E continua, "a rigor, há arbítrio na lei, no seu apriorismo, na sua abstração, na sua dureza. Nas mãos dos juízes, o texto deixa de ser arbítrio, humanizando-se, sensibilizando-se, adaptando-se à vida e à personalidade de cada homem. Portanto, é a lei que renuncia ao seu egoísmo e vai palpitar, ao ritmo flagrante do convívio social, através da toga. Os mandamentos legais são frios e autoritários. Para o homicídio – de 12 a 30 anos. Por quê? Para quê? Com a liberdade dos juízes responsáveis, não somente em atenção a circunstâncias convencionalmente enumeradas, e sim à realidade integral de cada homem e de cada fato". Para ele, "enquanto se mantiver, com a seleção moral e intelectual, a independência da magistratura, o arbítrio judicial, regulado cautelosamente, como fez o Código, só poderá ser salutar".

Deste modo, o magistrado que fixa os aumentos levando em conta somente o número de circunstâncias e não a suas valorações concretas, age com um automatismo que leva à injustiça e faz pouco de sua toga.

Portanto, o grau do aumento depende mais da intensidade concreta das circunstâncias que da extensão com que são encontradas.

Não se nega, contudo, que alguns julgadores ainda se valem do antigo método da pena mínima e do tabelamento de aumentos. Todavia, agindo contra toda a jurisprudência dos tribunais superiores, é dever justificar a heterodoxia.

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais, anoto que o delito foi cometido por duas pessoas, circunstância que enseja especial desvalor pelo legislador. Como basta a circunstância da noite para qualificar o delito, em razão do concurso de pessoas aumento a pena em seis meses.

Na primeira fase da dosimetria é possível a utilização de fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior ao fato objeto da acusação, pois a exigência de trânsito em julgado anterior é relativa somente à reincidência. Neste sentido se orientam as duas turmas do STJ ("A condenação por fato anterior ao delito que aqui se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal", STJ, 5ª Turma, HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013; em sentido análogo STJ, 6ª Turma, AgRg no REsp 1470846, Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 03/09/2015). Anoto também que Sidney possui um mau antecedente por tráfico (autos 0000580-03.2021.8.26.0549) e outro por posse de drogas para consumo pessoal (autos 1500187-38.2020.8.26.0549). Por conta disso aumento a pena em mais seis meses. A pena-base de Gabriel fica em um ano de detenção e a de Sidney em um ano e seis meses de detenção.

Segunda etapa. Presente a atenuante da menoridade relativa (inciso II do art. 65 do Código Penal) para Gabriel, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em detenção de 10 meses.

Terceira etapa. Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena.

Tratando-se de condenados não reincidentes e com pena inferior a quatro anos, o regime inicial adequado é o aberto.

Anoto que Sidney já estava em cumprimento de pena imposta em razão de outro processo, circunstância que indica a inadequação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de outros direitos.
Os maus antecedentes também impedem a suspensão condicional da pena.
Substituo a sanção corporal de Gabriel por prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR GABRIEL FELIPE DE OLIVEIRA à pena de detenção, pelo prazo de 10 meses, em regime inicial aberto, em virtude da conduta típica descrita no topo do artigo 150 do Código Penal e CONDENAR SIDNEY RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR à pena de detenção, pelo prazo de um ano e seis meses, em regime inicial aberto, em virtude da conduta típica descrita artigo 150, §1º, do Código Penal.
Substituo a pena de Gabriel por prestação de serviços à comunidade.

Deixo de condenar os acusados ao pagamento das custas e despesas processuais em razão do art. 55 da Lei 9.099/95.
Para a via recursal, observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhes foram nomeados advogada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.
Oportunamente, com o trânsito em julgado, procedam-se às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Porto Ferreira, 21 de junho de 2022.

Valdemar Bragheto Junqueira - Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA